Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
6ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de Porto Alegre

Rua Manoelito de Ornelas, 50 - Bairro: Praia de Belas - CEP: 90110230 - Fone: (51) 3210-6500 - Balcão virtual (51) 997893836 - Email: frpoacent6vciv@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5206616-54.2023.8.21.0001/RS

AUTOR: RODRIGO SOARES BERTELLI

RÉU: UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MEDICA LTDA

SENTENÇA

RODRIGO SOARES BERTELLI ajuizou **ação de obrigação de fazer** contra UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MÉDICA LTDA aludindo ser usuário de plano de saúde ofertado pela requerida. Aduziu que apresenta grave quadro de depressão e ansiedade e que, desde o diagnóstico, está fazendo tratamento terapêutico e medicamentoso, sem obter sucesso na remissão dos sintomas depressivos. Em 2023, foi diagnosticado com Transtorno Depressivo Persistente (CID 10 F34.1), não respondendo adequadamente aos diferentes tratamentos farmacológicos que lhe foram prescritos, motivo pelo qual o médico assistente recomendou o procedimento de Estimulação Magnética Transcraniana (EMT), que não foi autorizado pela requerida, por não constar no rol das coberturas obrigatórias dispostas na Resolução Normativa n.º 465/2021 da ANS. Discorreu sobre a eficácia do procedimento recomendado para o tratamento da depressão. Requereu que a demandada fosse compelida a fornecer o tratamento prescrito em sede de antecipação de tutela. Postulou a procedência da ação (evento 1, INIC1). Juntou documentos.

Determinada emenda da inicial para esclarecimentos quantos aos médicos que acompanham o autor e os medicamentos já utilizados (evento 5, DESPADEC1).

O autor emendou a inicial (evento 8, PET1) e juntou documentos.

A antecipação da tutela foi deferida e determinada a citação (evento 10, DESPADEC1).

O autor noticiou o descumprimento da decisão liminar (evento 16, PET1).

Determinada a intimação da demandada (evento 18, DESPADEC1), que comprovou o cumprimento da decisão (evento 24, PET2).

UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MÉDICA LTDA apresentou contestação. Preliminarmente, impugnou o valor atribuído à causa. No mérito, argumentou que negativa na cobertura pretendida pelo autor está embasada no fato de o procedimento não encontrar previsão no rol de Procedimentos da ANS. Aduziu que não foi colacionada evidência científica e a recomendação do CONITEC ou outro órgão técnico com renome. Apontou que o médico assistente não indicou a impossibilidade de utilização dos tratamentos que o Rol da ANS prevê e que teriam cobertura pelo plano de saúde para o tratamento da moléstia do autor. Requereu o acolhimento da preliminar e a improcedência da ação (evento 29, CONT1). Juntou documentos.

A UNIMED informou que a tentativa de contato com o autor para o agendamento da sessão restou inexistoso (evento 35, PET1).

Sobreveio réplica (evento 36, RÉPLICA1).

O autor comunicou o cumprimento da antecipação de tutela desde dezembro de 2023 (evento 39, PET1).

Instadas a dizerem sobre a produção de provas (evento 42, DESPADEC1), as partes postularam o julgamento do feito (evento 50, PET1 e evento 55, PET1).

Vieram os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

DECIDO.

O pedido inicial comporta julgamento antecipado, na forma do art. 355, I, do CPC, porquanto a prova documental produzida nos autos é suficiente ao desate da controvérsia e as partes não manifestaram interesse na dilação probatória.

Impugnação ao valor da causa

A parte ré sustenta que o valor da causa, em ações da espécie, deve corresponder ao valor pago pelo usuário ao plano de saúde a título de mensalidades, limitadas a uma anuidade contratual, por força do §2º do art. 292 do CPC.

Na hipótese dos autos, cuida-se de obrigação de fazer por tempo determinado, através da qual a parte autora busca a cobertura pela demandada do tratamento indicado pelo seu médico assistente, tendo sido atribuído à causa o valor de R$ 30.000,00 correspondente ao custo do tratamento para a quantidade das sessões prescritas.

Com efeito, nas causas em que se busca a cobertura de tratamento médico, afigura-se cabível atribuir à causa - ou considerar no montante a ser atribuído - o valor referente ao custo do tratamento, com fulcro no art. 292, §2º, do CPC, procedimento que foi adotado pelo autor.

Nesse sentido, ainda, cita-se:

> *APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DO FÁRMACO NINTEDANIBE. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. ART. 485, INC. IX, DO CPC. MANTIDA A REJEIÇÃO À IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. 1.**É CASO DE MANTER-SE O AFASTAMENTO DA IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA, TENDO EM VISTA QUE NAS CAUSAS EM QUE SE BUSCA A COBERTURA DE TRATAMENTO MÉDICO, AFIGURA-SE CABÍVEL ATRIBUIR À CAUSA - OU CONSIDERAR NO MONTANTE A SER ATRIBUÍDO - O VALOR REFERENTE AO CUSTO DO TRATAMENTO, COM FULCRO NO ART. 292, § 2º, DO CPC. 2. NO CASO, CONFORME INCLUSIVE REAFIRMADO NAS CONTRARRAZÕES APRESENTADAS AO RECURSO, O VALOR PARA AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DO MEDICAMENTO NINTEDANIBE 150MG, À ÉPOCA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO, ERA DE R$ 15.796,54, O QUAL, MULTIPLICADO POR 12 MESES, RESULTA NO VALOR DE R$ 189.558,49. 3. DESTARTE, ENCONTRA-SE CORRETO O VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA.** 4. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS, EM ATENÇÃO AO PRECONIZADO PELO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO DESPROVIDA.(Apelação Cível, Nº 50100848320188210001, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Julgado em: 31-05-2023) Grifei.*

Assim, deixo de acolher a preliminar suscitada.

Cumprimento da decisão liminar

A antecipação de tutela foi deferida nos seguintes termos (evento 10, DESPADEC1):

> *Destarte, CONCEDO a tutela de urgência, com fundamento no artigo 300, §2º, do CPC, para o fim de determinar que a ré UNIMED autorize e proceda ao custeio, **no prazo de 05 dias, a contar da citação**, do tratamento prescrito ao autor, por meio de Estimulação Magnética Transcraniana - EMT, no equivalente, por ora, a 50 sessões, sob pena de multa diária por dia de descumprimento, no valor de R$ 1.000,00, limitada a 30 dias-multa.*

Com efeito, a carta de citação e intimação da UNIMED foi recebida em 03/11/2023 (evento 15, AR1), contudo, a efetiva autorização para realização do procedimento foi noticiada ao autor em 23/11/2023 (evento 24, EMAIL10).

Assim, impõe-se a consolidação da multa diária fixada pelo período que a demandada atrasou no cumprimento da decisão, que deveria ter sido atendida até 10/11/2023.

Nos termos do art. 219 do CPC, computando-se os dias úteis do período de 10/11/2023 a 23/11/2023, obtém-se uma diferença de 9 dias, sobre os quais incidem as astreintes no valor de R$ 1.000,00.

Destaca-se, ainda, que as astreintes são inacumuláveis com juros de mora, haja vista a natureza cominatória da imposição. O débito de natureza cominatória sofre somente a incidência da correção monetária, sem a capitalização de juros moratórios sobre o total, a evitar o *bis in idem*.

MÉRITO

Inicialmente, destaco que incidem à espécie as disposições do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a situação dos autos se enquadra no disposto pelo seu art. 3º, §2º, devendo, portanto, as cláusulas contratuais respeitarem as regras dispostas na legislação consumerista. Nestes termos, também, a Súmula 608 do STJ: *Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.*

Incontroverso que o autor é beneficiário de plano de assistência à saúde operado pela requerida, tratando-se de contrato regulamentado pela Lei dos Planos de Saúde (n.º 9.656/98).

Incontroversa, outrossim, a patologia do autor, Transtorno Depressivo Persistente (CID 10 F34.1) e a recomendação médica para a realização de Estimulação Magnética Transcraniana (EMT), no total de 40 sessões diárias e mais 10 sessões semanais como manutenção (evento 1, LAUDO8).

A controvérsia reside na legitimidade da negativa de cobertura do tratamento pelo plano de saúde, fundamentado na circunstância de que o referido procedimento não consta no rol de cobertura obrigatória disposto na Resolução Normativa n.º 465/2021 da Agência Nacional de Saúde Complementar.

A requerida não nega haver cobertura no plano de saúde para a patologia que acomete o autor e inexiste no contrato trazido aos autos exclusão expressa quanto ao mal do qual ele padece (evento 1, CONTR53), tampouco há exclusão quanto à cobertura do tratamento prescrito.

Com efeito, o fato de o procedimento de Estimulação Magnética Transcraniana não estar previsto no rol da ANS não se revela como fundamento para óbice à cobertura, na medida em que é aquele indicado para o tratamento da patologia no estágio em que se encontra, encargo que incumbe ao médico assistente do autor, e não ao plano de saúde.

No que concerne ao tema da taxatividade do rol da ANS, a questão foi alvo de polêmica judicial e legislativa, sendo que, inicialmente, o Superior Tribunal de Justiça determinou que o rol da ANS era taxativo, em regra (EREsp 1886929/SP).

Não obstante, posteriormente ao julgamento realizado pelo STJ, sobreveio a Lei n.º 14.454/2022, alterando dispositivos da Lei n.º 9.656/1998. Nesse sentido, a partir da iniciativa do Poder Legislativo, alterou-se a legislação para assentar que o rol da ANS constitui referência básica para o fornecimento dos tratamentos pleiteados às operadoras de planos de saúde.

Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto:

[...]

§ 12. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1º de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde.

A partir disso, a aplicação de tratamentos não previstos no rol da ANS passou a depender da comprovação de dois requisitos, colocados pelo §13 da legislação:

§ 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que:

I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou

II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.

No caso, há indicação médica por profissional habilitado, além da Resolução n.º 1.986/2012, do Conselho Federal de Medicina, que reconhece a eficácia da técnica para o tratamento de depressões (evento 1, OUT21), bem como nota técnica do e-NatJus, no sentido da segurança e eficácia do procedimento para o tratamento de transtorno depressivo grave (evento 1, OUT22), restando, assim, preenchidos os requisitos previstos no art. 10, §13, I e II, da Lei n.º 14.454/2022.

Ainda sobre as evidências científicas do procedimento de Estimulação Magnética Transcraniana, cita-se:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PLANOS E SEGUROS DE SAÚDE. DIVERGÊNCIA ENTRE AS TURMAS DE DIREITO PRIVADO ACERCA DA TAXATIVIDADE OU NÃO DO ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE ELABORADO PELA ANS. ATRIBUIÇÃO DA AUTARQUIA, INEQUIVOCAMENTE ESTABELECIDA NA SUA PRÓPRIA LEI DE CRIAÇÃO. ATO ESTATAL DO REGIME JURÍDICO DE DIREITO ADMINISTRATIVO AO QUAL SE SUBMETEM FORNECEDORES E CONSUMIDORES DA RELAÇÃO CONTRATUAL DE DIREITO PRIVADO. GARANTE A PREVENÇÃO, O DIAGNÓSTICO, A RECUPERAÇÃO E A REABILITAÇÃO DE TODAS AS ENFERMIDADES. SOLUÇÃO CONCEBIDA E ESTABELECIDA PELO LEGISLADOR PARA EQUILÍBRIO DOS INTERESSES DAS PARTES DA RELAÇÃO CONTRATUAL. ENUNCIADO N. 21 DA I JORNADA DE DIREITO DA SAÚDE DO CNJ. CDC. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA À RELAÇÃO CONTRATUAL, SEMPRE VISANDO O EQUILÍBRIO. HARMONIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DA PRIMEIRA E SEGUNDA SEÇÕES NO SENTIDO DE VELAR AS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E A DISCRICIONARIEDADE TÉCNICA DA AUTARQUIA ESPECIALIZADA. FIXAÇÃO DA TESE DA TAXATIVIDADE, EM REGRA, DA RELAÇÃO EDITADA PELA AGÊNCIA, COM ESTABELECIMENTO DE PARÂMETROS OBJETIVOS PARA SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS SUBMETIDAS AO JUDICIÁRIO.
1. A Lei n. 9.961/2000 criou a ANS, estabelecendo no art. 3º sua finalidade institucional de promover a defesa do interesse público na assistência suplementar à saúde, regulando as operadoras setoriais, inclusive quanto às suas relações com prestadores e consumidores, contribuindo para o desenvolvimento das ações de saúde no País. Já o art. 4º, III, elucida que compete à ANS elaborar o Rol de procedimentos e eventos em saúde, que constituirão referência básica para os fins do disposto na Lei n. 9.656, de 3 de junho de 1998, e suas excepcionalidades.
2. Por inequívoca opção do legislador, extrai-se tanto do art. 10, § 4º, da Lei n. 9.656/1998 quanto do art. 4º, III, da Lei n. 9.961/2000 que é atribuição dessa agência elaborar o Rol de procedimentos e eventos em saúde que constituirão referência básica para os fins do disposto na Lei dos Planos e Seguros de Saúde. Nessa toada, o Enunciado n. 21 da I Jornada de Direito da Saúde do CNJ propugna que se considere, nos contratos celebrados ou adaptados na forma da Lei n. 9.656/1998, o Rol de procedimentos de cobertura obrigatória elencados nas resoluções da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ressalvadas as coberturas adicionais contratadas.
3. Por um lado, a Resolução Normativa ANS n. 439/2018, ora substituída pela Resolução Normativa ANS n. 470/2021, ambas dispondo sobre o rito processual de atualização do Rol, estabelece que as propostas de sua atualização serão recebidas e analisadas mediante critérios técnicos relevantes de peculiar complexidade, que exigem alto nível de informações, quais sejam, utilização dos princípios da avaliação de tecnologias em saúde - ATS, princípios da saúde baseada em evidências - SBE, manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do setor. Por outro lado, deixando claro que não há o dever de fornecer todas e quaisquer coberturas vindicadas pelos usuários dos planos de saúde, ao encontro das mencionadas resoluções normativas da ANS, a Medida Provisória n. 1.067, de 2 de setembro de 2021, incluiu o art. 10-D, § 3º, I, II e III, na Lei 9.656/1998 para estabelecer, no mesmo diapasão do regramento infralegal, a instituição da Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, à qual compete assessorar a ANS nas atribuições de que trata o § 4º do art. 10, devendo apresentar relatório que considerará: I - as evidências científicas sobre a eficácia, a acurácia, a efetividade e a segurança do medicamento, do produto ou do procedimento analisado, reconhecidas pelo órgão competente para o registro ou a para a autorização de uso; II - a avaliação econômica comparativa dos benefícios e dos custos em relação às coberturas já previstas no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, quando couber; e III - a análise de impacto financeiro da ampliação da cobertura no âmbito da saúde suplementar.
4. O Rol mínimo e obrigatório de procedimentos e eventos em saúde constitui relevante garantia do consumidor para assegurar direito à saúde, a preços acessíveis, contemplando a camada mais ampla e vulnerável economicamente da população. Por conseguinte, considerar esse mesmo rol meramente exemplificativo - devendo, ademais, a cobertura mínima, paradoxalmente, não ter limitações definidas - tem o condão de efetivamente padronizar todos os planos e seguros de saúde e restringir a livre concorrência, obrigando-lhes, tacitamente, a fornecer qualquer tratamento prescrito para garantir a saúde ou a vida do segurado, o que representaria, na verdade, suprimir a própria existência do "Rol mínimo" e, reflexamente, negar acesso à saúde suplementar à mais extensa faixa da população.
5. A par de o Rol da ANS ser harmônico com o CDC, a Segunda Seção já pacificou que "as normas do CDC aplicam-se apenas subsidiariamente nos planos de saúde, conforme previsão do art. 35-G da Lei nº 9.656/1998. De qualquer maneira, em casos de incompatibilidade de normas, pelos critérios da especialidade e da cronologia, há evidente prevalência da lei especial nova" (EAREsp n. 988.070/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 8/11/2018, DJe de 14/11/2018). Dessa maneira, ciente de que o Rol da ANS é solução concebida pelo próprio legislador para harmonização da relação contratual buscada nas relações consumeristas, também não caberia a aplicação insulada do CDC, alheia às normas específicas inerentes à relação contratual.
6. Não se pode perder de vista que se está a discutir direitos e obrigações da relação contratual que envolvem plano de saúde e usuário, e não o estabelecimento de obrigação de fazer ou de não fazer a terceiro, que nem mesmo integra a lide. A ANS, ao contrário do médico-assistente da parte litigante, analisa os procedimentos e eventos sob perspectiva coletiva, tendo em mira a universalização do serviço, de modo a viabilizar o atendimento do maior número possível de usuários. Mesmo o

correto e regular exercício profissional da Medicina, dentro das normas deontológicas da profissão, usualmente possibilita ao profissional uma certa margem de subjetividade, que, por vezes, envolve convicções pessoais ou melhor conveniência, mas não pode nortear a elaboração do Rol.

7. Conforme adverte a doutrina especializada, muito além de servir como arrimo para precificar os valores da cobertura básica e mínima obrigatória das contratações firmadas na vigência da lei de Planos de Saúde, o Rol de procedimentos, a cada nova edição, delineia também a relevante preocupação do Estado em não expor o consumidor e paciente a prescrições que não encontrem respaldo técnico estudado e assentado no mundo científico, evitando-se que virem reféns dos interesses - notadamente econômicos - da cadeia de fornecedores de produtos e serviços que englobam a assistência médico-hospitalar e odontológica suplementar.

8. Legítima é a confiança que está de acordo com o direito, despertada a partir de circunstâncias objetivas. Com efeito, o entendimento de que o Rol - ato estatal, com expressa previsão legal e imperatividade inerente, que vincula fornecedores e consumidores - deve ser considerado meramente exemplificativo em vista da vulnerabilidade do consumidor, isto é, lista aberta sem nenhum paralelo no mundo, ignora que é ato de direito administrativo, e não do fornecedor de serviços, assim como nega vigência a diversos dispositivos legais, ocasionando antisseleção, favorecimento da concentração de mercado e esvaziamento da competência atribuída à ANS pelo Poder Legislativo para adoção de medidas regulatórias voltadas a equilibrar o setor de saúde suplementar de forma ampla e sistêmica, com prejuízo para toda a coletividade envolvida. Afeta igualmente a eficácia do direito constitucional à saúde (art. 196 da CF), pois a interferência no equilíbrio atuarial dos planos de saúde privados contribui de forma significativa para o encarecimento dos produtos oferecidos no mercado e para o incremento do reajuste da mensalidade no ano seguinte, dificultando o acesso de consumidores aos planos e seguros, bem como sua mantença neles, retirando-lhes a confiabilidade assegurada pelo Rol de procedimentos, no que tange à segurança dos procedimentos ali elencados, e ao Sistema Único de Saúde (SUS), que, com esse entendimento jurisprudencial, reflexamente teria sua demanda aumentada.

9. Em recentes precedentes específicos envolvendo a supressão das atribuições legais da ANS, as duas Turmas de Direito Público decidiram que, "segundo entendimento firmado neste Superior Tribunal de Justiça, até prova cabal em contrário, deve prevalecer a presunção de legitimidade dos atos administrativos praticados pelas agências reguladoras", "sendo inviável qualquer discussão acerca do próprio mérito administrativo" (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.834.266/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 22/3/2021, DJe de 25/3/2021). Ademais, assentaram que não é papel do Judiciário promover a substituição técnica por outra concepção defendida pelo julgador, sendo "incabível substituição da discricionariedade técnica pela discricionariedade judicial" (AgInt no REsp n. 1.823.636/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 16/9/2021).

10. Diante desse cenário e buscando uma posição equilibrada e ponderada, conforme o entendimento atual da Quarta Turma, a cobertura de tratamentos, exames ou procedimentos não previstos no Rol da ANS somente pode ser admitida, de forma pontual, quando demonstrada a efetiva necessidade, por meio de prova técnica produzida nos autos, não bastando apenas a prescrição do médico ou odontólogo que acompanha o paciente, devendo ser observados, prioritariamente, os contidos no Rol de cobertura mínima. Deveras, como assentado pela Corte Especial na esfera de recurso repetitivo, REsp n. 1.124.552/RS, o melhor para a segurança jurídica consiste em não admitir que matérias técnicas sejam tratadas como se fossem exclusivamente de direito, resultando em deliberações arbitrárias ou divorciadas do exame probatório do caso concreto. Ressaltou-se nesse precedente que: a) não é possível a ilegítima invasão do magistrado em seara técnica à qual não é afeito; b) sem dirimir a questão técnica, uma ou outra conclusão dependerá unicamente do ponto de vista do julgador, manifestado quase que de forma ideológica, por vez às cegas e desprendido da prova dos autos; c) nenhuma das partes pode ficar ao alvedrio de valorações superficiais.

11. Cabem serem observados os seguintes parâmetros objetivos para admissão, em hipóteses excepcionais e restritas, da superação das limitações contidas no Rol: 1 - o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo; 2 - a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do Rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado à lista; 3 - é possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extrarrol; 4 - não havendo substituto terapêutico ou estando esgotados os procedimentos do Rol da ANS, pode haver, a título de excepcionalidade, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo-assistente, desde que (i) não tenha sido indeferida expressamente pela ANS a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e NatJus) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS.

12. No caso concreto, a parte autora da ação tem esquizofrenia paranoide e quadro depressivo severo e, como os tratamentos medicamentosos não surtiram efeito, vindica a estimulação magnética transcraniana - EMT, ainda não incluída no Rol da ANS. O Conselho Federal de Medicina - CFM, conforme a Resolução CFM n. 1.986/2012, reconhece a eficácia da técnica, com indicação para depressões uni e bipolar, alucinações auditivas, esquizofrenias, bem como para o planejamento de neurocirurgia, mantendo o caráter experimental para as demais indicações. Consoante notas técnicas de NatJus de diversos Estados e do DF, o procedimento, aprovado pelo FDA norte-americano, pode ser mesmo a solução imprescindível para o tratamento de pacientes que sofrem das enfermidades do recorrido e não responderam a tratamento com medicamentos - o que, no ponto, ficou incontroverso nos autos.

13. Com efeito, como o Rol não contempla tratamento devidamente regulamentado pelo CFM, de eficácia comprovada, que, no quadro clínico do usuário do plano de saúde e à luz do Rol da ANS, é realmente a única solução imprescindível ao tratamento de enfermidade prevista na Classificação Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde - CID, notadamente por não haver nas diretrizes da relação editada pela Autarquia circunstância clínica que permita essa cobertura, é forçoso o reconhecimento do estado de ilegalidade, com a excepcional imposição da cobertura vindicada, que não tem preço significativamente elevado.

14. Embargos de divergência a que se nega provimento.

(EREsp n. 1.886.929/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 8/6/2022, DJe de 3/8/2022.) Grifei.

Nesse mesmo sentido, o TJRS:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DEPRESSIVO RECORRENTE. ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA - EMT. EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS. COBERTURA DEVIDA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REDISCUSSÃO. PREQUESTIONAMENTO. DESACOLHIMENTO. 1) Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão que negou provimento ao recurso de apelação da parte autora, mantendo a r. sentença de procedência da ação de obrigação de fazer, condenando a parte ré a cobertura do tratamento médico de Estimulação Magnética Transcraniana (EMT). 2) Os embargos de declaração se constituem como espécie de recurso expressamente previsto no artigo 994, inciso IV do CPC/2015. A sua aplicabilidade está delimitada no artigo 1.022 da legislação Processual Civil, o qual preceitua taxativamente as hipóteses em que a sua oposição é cabível, quais sejam: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deve se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. 3) Nas razões dos declaratórios, o embargante sustentou omissão no acórdão quanto a abordagem do artigo 10, § 4º, da Lei n.º 9.656/981, que estabelece que, em se tratando de contrato regulamentado, as normas editadas pela ANS definem a amplitude das coberturas. Aduziu que o acórdão também restou omisso ao não enfrentar o artigo 1º, § 1º da Lei n.º 9.656/98. Entretanto, essas questões versadas nos aclaratórios foram devida e escorreitamente esclarecidas, debatidas no corpo do acórdão embargado, (transcrição abaixo) razão pela qual, não se trata

de obscuridade, contradição ou eventual omissão à luz do art. 1022 do CPC. 4) O acórdão embargado assim dispôs sobre o tema: ***(...) No caso dos autos, resta incontroverso que o autor é acometido de episodio depressivo grave, refratário ao uso das medicações, conforme laudo médico acostado (Evento 1, LAUDO9) e, muito embora, inexista previsão da Estimulação Magnética Transcraniana - EMT no rol da ANS, é cabível a sua mitigação, porquanto, conforme consulta ao sistema E-NATJUS, a Nota Técnica nº 89072, de 09/08/2022, aponta a existência de evidências científicas para casos análogos, que amparam o pedido.*** *5) O julgador não está adstrito a enfrentar todos os dispositivos constitucionais/legais invocados pelas partes, desde que expresse seu convencimento acerca da matéria em decisão devidamente fundamentada. 6) Com efeito, não se verifica a omissão apontada, uma vez que os embargos declaratórios não se prestam para a rediscussão da causa, pois constituem recurso de integração e não de substituição, pelo que, imperiosa a manutenção da decisão embargada. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS.(Apelação Cível, Nº 50865548720208210001, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em: 31-08-2023) Grifei.*

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSTORNO DE HUMOR BIPOLAR. EPISÓDIO DEPRESSIVO GRAVE. TRATAMENTO DE ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA. DEVER DE COBERTURA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RETORNO DO STJ. NOVO JULGAMENTO. ***1. HIPÓTESE DE DIAGNÓSTICO DE TRANSTORNO DE HUMOR BIPOLAR ATUAL EPISÓDIO DEPRESSIVO GRAVE E INEFICÁCIA DO TRATAMENTO CONVENCIONAL. RECOMENDAÇÃO MÉDICA DO TRATAMENTO ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA. 2. SUFICIENTE COMPROVAÇÃO DA EFICÁCIA DO PROCEDIMENTO À LUZ DAS CIÊNCIAS DA SAÚDE, BASEADA EM EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS E PLANO TERAPÊUTICO, CONFORME NOTAS TÉCNICAS DO E-NATJUS.*** *RECURSO DESPROVIDO, EM NOVO JULGAMENTO.(Apelação Cível, Nº 50023631920208211001, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em: 26-07-2023) Grifei.*

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DEPRESSIVO RECORRENTE. ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA - EMT. EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS. COBERTURA DEVIDA. ***Trata-se de ação de obrigação de fazer através da qual a parte autora busca cobertura para a realização de tratamento médico de Estimulação Magnética Transcraniana, tendo em vista que foi diagnosticado com Transtorno Depressivo Recorrente Grave, julgada procedente na origem. Em razão da vigência da Lei n. 14.454/22, restaram estabelecidos critérios para permitir a cobertura de exames ou tratamentos de saúde não incluídos no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Ans. De acordo com o referido diploma legal, tratamentos e exames fora do rol da ANS deverão ser aceitos, desde que cumpram uma das condicionantes estabelecidas, quais sejam: ter eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ter recomendações da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec); ou ter recomendação de, no mínimo, um órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional. No caso dos autos, resta incontroverso que o autor é acometido de episodio depressivo grave, refratário ao uso das medicações, conforme laudo médico acostado (Evento 1, LAUDO9) e, muito embora, inexista previsão da Estimulação Magnética Transcraniana - EMT no rol da ANS, é cabível a sua mitigação, porquanto, conforme consulta ao sistema E-NATJUS, a Nota Técnica nº 89072, de 09/08/2022, aponta a existência de evidências científicas para casos análogos, que amparam o pedido.*** *Sentença mantida. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA(Apelação Cível, Nº 50865548720208210001, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em: 23-06-2023) Grifei.*

Nesse cenário, reconheço a ilicitude da negativa ao fornecimento do tratamento de Estimulação Magnética Transcraniana, razão pela qual o feito merece juízo de procedência para, confirmando a tutela de urgência concedida, determinar à demandada o fornecimento do tratamento indicado pelo profissional médico assistente do autor, na quantidade prevista no laudo (40 sessões diárias e 10 sessões semanais como manutenção).

Por fim, havendo superveniente alteração na quantidade de sessões necessárias, e assemelhando-se a situação dos autos, a conclusão exposta neste *decisium* não difere, devendo a parte ré observar o receituário do médico assistente da parte autora.

Diante do exposto, na forma do art. 487, I, do CPC, **JULGO PROCEDENTES** os pedidos formulados na ação ajuizada por RODRIGO SOARES BERTELLI contra UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MÉDICA LTDA para:

a) RATIFICAR a tutela de urgência outrora deferida;

b) CONDENAR a parte ré à cobertura do tratamento prescrito ao autor, vale dizer, Estimulação Magnética Transcraniana, no total de 40 sessões diárias e 10 sessões semanais como manutenção;

c) CONDENAR a demandada ao pagamento da multa diária outrora fixada pelo descumprimento da decisão liminar, no valor de R$ 9.000,00, a ser corrigida monetariamente pelo IPCA a contar da data do arbitramento.

Sucumbente, arcará a parte ré com o pagamento da Taxa Única de Serviços Judiciais e despesas processuais, bem como honorários de advogado da parte adversa, que fixo em 15% sobre o valor atualizado da causa, corrigido monetariamente pelo IPCA desde o ajuizamento da ação (Súmula 14 do STJ), acrescido de juros de mora desde o trânsito em julgado, observados o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (art. 85, §2º, do CPC).

Tendo em vista a sistemática do Código de Processo Civil e, diante da inexistência de juízo de admissibilidade, conforme dispõe o art. 1.010, §3º, do CPC, em caso de interposição de recurso de apelação, proceda-se à intimação da parte apelada para que apresente contrarrazões, querendo, no prazo de 15 dias. Decorrido o prazo, subam os autos ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul.

Com o trânsito em julgado, nada requerido no prazo de 5 dias, e satisfeitas eventuais custas pendentes, baixe-se.

Caso não seja efetuado o pagamento das custas, oficie-se ao TJRS, a fim de informar o não pagamento, nos termos do Ato n.º 072/2022 - P.

Sentença publicada e registrada eletronicamente.

Documento assinado eletronicamente por **DEISE FABIANA LANGE VICENTE, Juíza de Direito**, em 10/7/2024, às 16:4:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10063050024v19** e o código CRC **c4ddfad4**.